

0028836-58.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... não fosse, o crime de associação para o tráfico é permanente, cuja consumação se protraí no tempo. Ante evidências da guarda de drogas e bens subtraídos, mormente a visualização do réu com dinheiro trocado nas mãos, dentro do imóvel, como se fizesse contabilidade do tráfico, corroborando o teor da denúncia. E não havendo condições ou tempo hábil para representação pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0028836-58.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0028836-58.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157536/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 18430884 - 04º D.P. GUARULHOS, 2827/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2157536 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN FRUTUOSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Vistos.

JONATHAN FRUTUOSO, vulgo "Negão", foi denunciado como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06 e por duas vezes no artigo 180, caput, do Código Penal, todos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal e em concurso material de delitos

(art. 69 do CP), porque, em período incerto, compreendido, no mínimo, entre os dias 30 de maio e 10 de junho de 2021, na Rua Porto Alegre, nº 141, Bairro Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, durante calamidade pública decorrente da pandemia causa pela doença COVID-19, associou-se com outros indivíduos não identificados, com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas na cidade de Guarulhos.

Consta também que, em período incerto, compreendido até o dia 10 de junho de 2021, por volta das 12h30, nas mesmas circunstâncias de lugar, o réu, durante calamidade pública decorrente da pandemia causa pela doença COVID-19, recebeu e ocultou, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CB250F Twister, da cor vermelha, placa original ainda desconhecida, que ostentava a placa adulterada CUJ 6820, pertencente ao veículo de João Alves de Andrade, bem que sabia ser produto de crime.

Consta ainda que, em período incerto, compreendido até o dia 10 de junho de 2021, por volta das 12h30, nas mesmas circunstâncias de lugar, o réu, durante calamidade pública decorrente da pandemia causa pela doença COVID-19, recebeu e ocultou, em proveito próprio, a motocicleta Honda/PCX 150 DLX, da cor branca, placa original ainda desconhecida, que ostentava a placa adulterada GDL1F88, pertencente ao veículo de Tatiane Leite Ramos, bem que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi oferecida (fls. 76/81). O réu foi notificado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação (fls. 100). A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 107).

Em instrução regular, foram ouvidas a vítima Tatiane, duas testemunhas comum à acusação e defesa, seguindo-se o interrogatório do réu.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público pediu a juntada dos laudos periciais e o desmembramento dos autos do Processo nº 1501572-29.2021.8.26.0535, o que deu ensejo à formação destes autos, cujo objeto é exclusivamente crime patrimonial. A defesa nada requereu. Nos autos do Processo nº 1501572-29.2021.8.26.0535 o acusado foi condenado e ao recurso interposto naquele autos foi negado provimento.

Com a juntada dos laudos nesses autos (fls. 192/194 e 218/225), as partes apresentaram alegações finais escritas. A representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso por duas vezes no art. 180 do CP. No tocante à dosimetria, pediu o reconhecimento da reincidência e do concurso material. Bateu-se pelo regime fechado.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Preliminarmente, sustentou a ilicitude de prova, uma vez que teria sido obtida mediante violação de domicílio. Subsidiariamente, pediu fixação da pena no mínimo legal, regime semiaberto, com detração, e concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, afasto a arguição de ilegalidade na obtenção da prova da materialidade delitiva, por não haver provas de invasão de domicílio, constando dos autos informações de que a porta estava aberta e havia fundadas suspeitas de crime permanente, que se confirmaram. De outro giro, ainda que assim não fosse, o crime de associação para o tráfico é permanente, cuja consumação se protraí no tempo. Ante evidências da guarda de drogas e bens subtraídos, mormente a visualização do réu com dinheiro trocado nas mãos, dentro do imóvel, como se fizesse contabilidade

do tráfico, corroborando o teor da denúncia. E não havendo condições ou tempo hábil para representação pelo mandado judicial, a diligência policial para prisão em flagrante estava autorizada legalmente enquanto perdurasse a situação ilícita. Neste sentido, por analogia:

“Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o Tráfico, em concurso material (artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal). Sentença condenatória. A Defesa de MAICON, em preliminar, busca o reconhecimento da nulidade da condenação, pelo reconhecimento das provas ilícitas, obtidas por violação de domicílio ou pelo reconhecimento da nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação judicialmente. No mérito, busca a absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das basilares no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão; a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; o abrandamento do regime prisional, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa de LUÍS busca a absolvição por ausência de provas de ambos os delitos. E, ainda, a Defesa de RAFAEL, em preliminar, alega a nulidade da ação em decorrência do vício na oitiva dos depoimentos das testemunhas de acusação. No mérito, busca a absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do privilégio; a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminares afastadas. Violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente que prescinde de mandado judicial. Inteligência do art. 5º, XI, da CF. No mérito, parcial acolhimento do recurso. Autoria e materialidade bem fundamentadas quanto ao tráfico. Réus presos em flagrante. Versões dos policiais válidas para embasar decreto condenatório. Condenações mantidas. Associação para o tráfico. Ausência de prova inequívoca relativa ao ânimo estável dos réus para a prática do delito. Absolvição necessária, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Dosimetria comporta reparo. Basilares devem retornar ao mínimo. Quantidade apreendida de entorpecentes que não pode ser considerada exagerada. Menoridade relativa e confissão reconhecidas, contudo, sem reflexo na pena. Súmula 231 do C. STJ. Diante da primariedade dos réus, deve ser reconhecido o redutor previsto no artigo 33, §4º, para ambos. Fixação do regime aberto necessário, nos termos do artigo 33, do Código Penal, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recursos defensivos providos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para os sentenciados LUÍS HENRIQUE e RAFAEL. Lapse de dois anos, aplicável na espécie (CP, art. 109, V, c.c. art. 115), ultrapassado entre a prolação da sentença e o r. acórdão. Extinção da pena pela prescrição. Expeça-se o alvará de soltura clausulado em favor dos acusados.” (TJSP; Apelação Criminal 0000334-87.2018.8.26.0621; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito e posse ilegal de arma e munição - Apreensão de quatro porções de crack, uma de maconha, balança de precisão, 19.000 microtubos vazios, arma e munição - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade do processo - Provas ilícitas, obtidas por meio de violação de domicílio - Inocorrência - Réus presos em flagrante por crimes de natureza permanente - Ingresso na moradia autorizado pela Constituição Federal - Nulidade não verificada - Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, comprovadas pelas declarações dos policiais militares - Potencialidade da arma e munição apreendidas, atestadas pelos laudos periciais - Revólver localizado na cama que WAGNER dormia, cujo quarto também estava e dormia JOSÉ, em imóvel que o último afirmou lhe pertencer - Delito de posse ilegal de arma cometido em comparsaria - Crimes, caracterizados - Condenações, mantidas - Dosimetria - JOSÉ: Básicas fixadas no piso e fixadas nesse patamar, com relação ao delito previsto no Estatuto do

Desarmamento - Réu beneficiado com a aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, no que tange ao crime de tráfico - WAGNER: Sanções majoradas em razão da presença de maus antecedentes e reincidência - Impossibilidade de substituição da carcerária por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum e da recidiva (CP, arts. 44, caput, I e II, e 77, caput e I) - Regime (fechado), único pertinente, in casu - Erro material relativo ao quantum das multas, retificado - Apelos não providos." (TJSP; Apelação Criminal 0000307-96.2015.8.26.0593; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).

Destarte, não há se falar na presença de provas ilícitas ou de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, muito menos na tese de contaminação dos frutos da árvore envenenada. A propósito, as demais provas não decorreram, exclusivamente, da busca e seriam produzidas, certamente, por meios independentes, enquadrando-se nas exceções que a jurisprudência adota para a aplicação da respectiva teoria.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de nº 2827/2021, lavrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos (fls. 11/15); auto de exibição e apreensão (fls. 16/17); fotografias (fls. 63/74); laudos de exames periciais acostados aos autos (fls. 192/194, 209/211 e 218/225) e prova oral a seguir examinada.

O réu negou vagamente a prática delitiva, alegando que estava no seu trabalho, quando os policiais chegaram e apreenderam o dinheiro, que era produto do encerramento da atividade de vendas e entregas de água. Sustentou desconhecimento das anotações para o tráfico. Admitiu que apenas uma das motos lhe pertencia e tinha sido adquirida pelo valor de cinco mil e quinhentos reais pela internet. Destacou que o dinheiro seria usado para pagar parte do saldo devedor. No entanto, não fez prova do pagamento, sendo de se esperar que tivesse acesso a recibo ou dados de sua movimentação financeira para tanto. Não forneceu os dados do vendedor e alegou vagamente que não acessa mais o Facebook. Esclareceu que a outra moto pertencia a um amigo, cujos dados também não forneceu. Afirmou que já foi acusado de tráfico, curiosamente também forjado. A versão vaga, isolada e inverossímil prestada em juízo acabou refutada pelas provas colhidas.

A vítima Tatiane asseverou que foi solicitada pela polícia, porque tinham encontrado sua moto, cujos dados haviam sido clonados. Soube que o réu tinha sido detido por tráfico de drogas e que em seu poder fora localizada uma moto igual a sua.

O policial Alexsandro informou que receberam denúncia anônima com o nome completo do réu no sentido de que era o gerente do tráfico na região. No local havia uma habitação coletiva e o avistaram pela janela sobre a cama, onde localizaram boa quantia de dinheiro, aproximadamente mil setecentos e quarenta e dois reais em notas trocadas. Indagado, ele prontamente admitiu que, por necessidade financeira, estava recolhendo o dinheiro do tráfico para repassar a um indivíduo que não quis identificar. Em seu poder também apreenderam um caderno com anotações, números e nomes típicos de contabilidade do tráfico. Aduziu que, na mesma edificação, encontraram duas motocicletas, cujos dados eram de proprietários moradores de outras localidades. Em contato com uma proprietária, souberam que se tratava de uma motocicleta clonada. Ele alegou que havia comprado de terceiro, mas sem fornecer dados para identificar origem.

O Policial Luiz Carlos confirmou que receberam denúncia anônima com o nome do acusado, seu endereço e a informação de que ele era o gerente do tráfico na região. No endereço, avistaram o réu pela janela contando dinheiro. Chamaram-no

pelo nome e ele atendeu, ainda com o dinheiro trocado nas mãos. Observou que ele admitiu, quando autuado, que estava fazendo "recolha" do tráfico por necessidades econômicas. Apreenderam ainda anotações de quantidades de drogas e valores, típicas da contabilidade do tráfico. Aduziu que, em um cômodo contíguo, localizaram duas motos. Indagado, o réu admitiu ter adquirido pela internet (Facebook), tendo mostrado dois documentos, um em nome de uma mulher e outro de um homem, residentes de cidades distantes. Entraram em contato com os proprietários das motos, cujas placas eram ostentadas, e eles disseram que estavam com os veículos. Não encontraram drogas, mas apenas o dinheiro.

Como se percebe, os crimes previstos no art. 180 do CP, narrados na denúncia, restaram devidamente comprovados. Segundo apurado, as motocicletas tiveram seus sinais de identificação adulterados, mediante acoplamento das placas de identificações (CUJ 6820 e GDL1F88) diversas das originais, cujos caracteres pertenciam a outros veículos, estes de origens lícitas. Ciente das procedências espúrias dos bens, o acusado os recebeu e passou a deles se utilizar para a prática de suas atividades ilícitas, além de ocultá-los nas dependências do imóvel onde residia. Entretanto, após receberem notícia anônima por meio do Disque Denúncia, versando sobre o tráfico de drogas desenvolvido pelo acusado na região, policiais civis, em diligências, dirigiram-se até o local indicado. Após ingressarem no imóvel do acusado, que se encontrava aberto, os policiais surpreenderam JONATHAN, dentro de um cômodo, efetuando a contabilidade da quantia em espécie de R\$ 1.742,00. Aprenderam também anotações sobre o tráfico de drogas. Indagado, o acusado informalmente admitiu o envolvimento na venda de drogas, como fonte daqueles valores. Na vistoria realizada no local, encontraram ainda as motocicletas utilizadas pelo acusado e constataram que eram veículos dublês, com placas correspondentes a veículos lícitos, cujos titulares estavam na posse regular de seus bens.

Em que pese eventual tese de defesa, restou claro que o acusado estava na posse das motocicletas dubles, com a consciência da origem criminosa. Não apresentou documentação apta a comprovar suposta posse ou obtenção lícita dos veículos. A defesa não conseguiu apresentar nenhum dado para desconstituir as robustas evidências do dolo apresentadas e para justificar a guarda, justamente, de duas motos com claro liame com os crimes patrimoniais antecedentes. Não indicou os antecessores na posse, sintomaticamente, e não demonstrou sequer as circunstâncias do recebimento e eventual aparência de licitude. Nada permite concluir por engano ou culpa. Muito pelo contrário, singela pesquisa, que todo adquirente faz, levaria o réu a saber da incompatibilidade das placas com os veículos e, portanto, da procedência delituosa. Nesse sentido, a Jurisprudência não discrepa da necessidade da análise circunstancial para verificação da culpabilidade, valendo a esclarecedora leitura dos seguintes arestos do E. Tribunal de Alçada Criminal deste Estado:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (TACRIM-SP. - 14a C. - Ap. 1.059.911/3 - Rel. San Juan França - RT 746/629).

"A prova nos crimes de receptação dolosa é sempre difícil, resumindo-se, geralmente, a dados e aspectos circunstanciais. É sólida a jurisprudência desta Corte no sentido de que a apreensão da 'res' em poder do agente gera presunção de autoria, que se converte em certeza, autorizando o desfecho condenatório, caso ausente justificativa plena e crível" (TACRIM-SP. - 13a C. - Ap. 1.081. 029-8 - Rel. Roberto Mortari).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente no conteúdo do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles

obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016)

Não convence, por outro lado, a tentativa de refutar o valor dos depoimentos, pois foram claros, seguros, coerentes e condizentes com os elementos sensíveis da infração, não existindo causa de suspeição concreta ou indício de mácula sobre a apreensão. Ressalte-se que não havia razão plausível para que os policiais, ainda que tivessem participado da prisão por associação para o tráfico, cuja reprimenda é mais gravosa, criassem fatos tão peculiares para prejudicá-lo (posse das motos dolosa), gratuita e aleatoriamente, submetendo-se ao risco de serem exonerados e responsabilizados criminalmente. Cumpre observar, ainda, que não despontou indício de crime funcional, que não incorreram em contradições e não denotaram insegurança. Enfim, não há fato concreto para desprezar as declarações de policiais incumbidos de relevante função pública, sob compromisso formal. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

Das provas extrai-se ainda que houve flagrante de crime permanente, cujas evidências foram notadas pelos policiais, antes do ingresso na casa. Assim, estavam autorizados à diligência, sem se cogitar de abuso de autoridade ou oposição justificada do réu à entrada na sua casa. A defesa, por sua vez, não indicou e não comprovou motivos para falsa incriminação pelos depoentes. Não demonstrou equívoco na apreensão e vício no resultado da persecução. Não apresentou indício de verossimilhança de explicação plausível para a conduta do denunciado e o apressamento, a despeito de suas condições evidentemente espúrias, de sorte a refutar as evidências da ciência do crime antecedente. Com efeito, as evidências, quando harmônicas, são suficientes à comprovação do delito de receptação, sobretudo diante da especificidade do tipo penal e da dificuldade na apreensão do pensamento dos autores de crimes deste jaez. Neste sentido, há orientação jurisprudencial:

"RECEPTAÇÃO - Dolo - Prova - Indícios e circunstâncias - Suficiência (TACrimSP)" RT 726/666.

É justamente o que ocorre, na situação em tela. Todos os fatos acima descritos não constituem mera coincidência, mas convergem na demonstração da consciência da origem ilícita pelo réu, a despeito das ponderações da defesa. Destarte, não pairam dúvidas de que ele tinha plena ciência da origem espúria das motocicletas, até porque em se tratando de crime de receptação, é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, o que, na vertente hipótese, não ocorreu. Em suma, todos os depoimentos e elementos colhidos evidenciam o dolo na obtenção e posse do bem.

Não se cuidou de negligência, mas de ciência inequívoca da ilicitude, não se cogitando de desclassificação para receptação culposa e, por conseguinte, de isenção de pena ou perdão. Neste sentido, é a jurisprudência:

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato." (TJ/SP, Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 10.11.2011).

"Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmutar em certeza a presunção de sua responsabilidade." (TJ/SP, Apelação n.º 0005986-38.2007.8.26.005, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 08.03.2012).

Por todo o exposto, diante das provas convincentes, obtidas ao longo de toda a persecução, e que não foram rechaçadas por nenhum subsídio concreto, é inarredável a condenação. No mais, ausente prova de excludente, a conduta é típica, antijurídica e culpável, nos termos do art. 180, caput, do CP.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, consistente em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa (art. 180 do CP), utilizada a condenação referente ao Processo Criminal Nº 0041859-18.2014.8.26.0224 (fls. 31/32) apenas para fins de reincidência, evitando-se o bis in idem.

Na segunda fase, haja vista a agravante da reincidência a pena é exasperada em 1/6 perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Não vislumbro presente a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, pois o delito não tem relação direta com a pandemia e o agente não se aproveitou de circunstâncias decorrentes do período de excepcionalidade, como ocorreria com corrupção no setor de saúde, fraudes de licitações correspondentes e outras situações análogas. Entendimento contrário exigiria a incidência do aumento da pena

sobre todas infrações, o que não condiz com a exegese teleológica e sistemática das normas do ordenamento pátrio sobre a matéria. A falta de nexo causal entre conduta do réu e pandemia e a ausência de satisfação dos fins de política criminal inerentes à previsão da agravante desaconselham o acolhimento do pedido do Parquet. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente infrator realizado em plena época da pandemia - Autoria e materialidade delitiva comprovadas quanto ao tráfico com envolvimento de adolescente - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Impossibilidade de admissão do tráfico privilegiado diante da prova colhida nos autos - Penas readequadas para se afastar o aumento na primeira fase diante da diversidade e quantidade, além da agravante presente com no artigo 61, inciso II, "j" do CP, diante da ausência do nexo de causalidade entre o fato praticado e o contexto da pandemia do Covid-19 em curso - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade - Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Criminal 1501582-16.2020.8.26.0533; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Na terceira fase, tendo em vista que ambas as receptações foram realizadas em contextos distintos, de rigor, o reconhecimento do concurso material de delitos. Destarte, as reprimendas são somadas, totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade e natureza do crime, de um lado (a desaconselhar o fechado), e a reincidência do acusado, de outro (a obstar o aberto). Não estão preenchidos, pelos mesmos motivos, mormente pela reincidência (art. 33 da lei de drogas), os requisitos do art. 44, do CP, com alterações da Lei 9714/98, até porque não socialmente recomendável e suficiente a substituição por restritivas de direito, sobretudo para fins pedagógicos, assim como o sursis.

A despeito da compreensível necessidade de tempo para outorga da prestação jurisdicional de primeira instância, não é possível conceber regime diverso, mediante estimativa da detração. Além de destoar da fundamentação da pena e da reincidência, a aplicação de regime diverso, sem correspondência com a disciplina legal da dosimetria, mas com base na duração da prisão provisória (sequer suficiente perante a quantidade da pena para detração), é desprovida de comprovação cabal dos requisitos. Aliás, não atentaria para a necessidade de cálculo para fins de progressão, eventual unificação de penas e verificação das condições subjetivas do sentenciado, inclusive comportamento carcerário, para análise do mérito da alteração de regime. Por conseguinte, não atenderia aos princípios da individualização da pena e da isonomia substancial.

Ante o exposto e mais o que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu JONATHAN FRUTUOSO, como incurso, por duas vezes, no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo a Lei.

O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, já que permaneceu preso até a presente decisão, sendo contraproducente sua soltura, neste lanço, em detrimento da aplicação da lei penal, após imposição de regime não aberto. Ademais, a reincidência e a gravidade das circunstâncias dos delitos tornam necessária a custódia como garantia da ordem pública. De qualquer modo, a execução provisória imediata não causará prejuízos ao acusado, que terá eventuais benefícios analisados com os dados necessários e cálculo exato. Recomende-se o acusado no ergástulo onde

se encontra. Expeça-se guia de recolhimento, oportunamente.

Deixo de arbitrar indenização em favor da vítima, por ora, por falta de pedido dos interessados (legitimados) e à míngua de dados seguros sob contraditório para estimativa precisa do prejuízo, o que poderá ocorrer em vias próprias, oportunamente.

Custas e Despesas processuais pelo sentenciado, respeitada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 08 de agosto de 2022.

GLÁUCIO ROBERTO BRITTES DE ARAUJO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA